

1500813-56.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500813-56.2022.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500813-56.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MARCATO BARRETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

DOUGLAS MARCATO BARRETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de maio de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Lázaro Maldonado, 429, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito, para futura entrega a terceiros, cento e quarenta porções de cocaína na forma de crack, pesando 367,70g, além de seiscentas e cinquenta e oito porções de cocaína em pó e na forma de crack, pesando 377,68g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portava, ainda, o réu, um rolo de plástico, uma balança, uma folha de caderno com anotações, três recipientes contendo carbonato de cálcio, um aparelho celular "Samsung" e R\$ 150,00.

Policiais militares, com informações de populares sobre a prática do comércio ilícito, abordaram o réu na via, localizando-se, em revista pessoal, o celular. Em seguida, por indicação do denunciado, efetivaram, os agentes, diligência na residência de "Giselia Perpétua Nunes", que mantinha relacionamento amoroso com o

réu, onde encontraram os entorpecentes, os petrechos e o dinheiro.

Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma apontada pela defesa.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear o crime.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante o estado de flagrância, constatado pelo encontro de entorpecentes, e, ao depois, ante autorização do réu e de familiares, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca.

Enquanto o agente executar o delito, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.035.493/AM, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.06.2022).

Além disso, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade, por parte dos agentes. Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social. Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação aos direitos do réu, que indicou existência do tóxico no imóvel, motivando o desfecho da diligência policial.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito. A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, que revela o encontro das porções das drogas, do celular, da balança, do dinheiro, do rolo de plástico, da folha de caderno com anotações e do carbonato de cálcio em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 30/32 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 78/80, concludentes no sentido de se tratar de cocaína, a substância encontrada.

A folha com anotações foi periciada às fls. 100/104.

Havia resquícios de "cocaína" na balança e no rolo de plástico (fls. 105/108). O aparelho celular foi vistoriado, constatando-se diálogos relativos à traficância (fls. 168/176).

Em ambas as manifestações, disse o réu ter sido contratado por indivíduo desconhecido para armazenar uma sacola contendo as drogas e os petrechos, por ele mantida na residência da namorada. Receberia R\$ 1.000,00 por semana, pelo serviço. Giselia Perpétua Nunes, companheira do denunciado, ouvida na fase administrativa, afirmou ter este deixado, no imóvel, uma sacola plástica, cujo conteúdo, só revelado no decorrer da diligência, revelou-se. Foi quando viu existirem drogas e os petrechos na sacola.

Explicaram os policiais terem informações de populares, sobre execução de comércio ilícito, propiciado a abordagem ao réu, caminhando na via, localizando-se, nas vestes, o aparelho celular. Continuaram no sentido de que, por indicação do denunciado, realizaram buscas na residência de "Giselia Perpétua Nunes", onde encontraram os entorpecentes, os petrechos e o dinheiro. Para tais testemunhas, admitiu o réu ser o proprietário do tóxico.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar o réu ou forjar o crime.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

A testemunha ouvida em nome da defesa nada acrescentou ao deslinde da questão.

Urge consignar ser grande a quantidade de drogas apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação atual de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação ou guarda do produto, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o

agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). Por fim, importa registrar que eventual dificuldade financeira, apontada pelo réu, não autorizaria, de forma alguma, a prática criminosa. Até porque, se assim não fosse, desnecessária seria a existência de normas legais, reguladoras do comportamento humano.

Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas. Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da elevada quantidade e da diversidade das substâncias encontradas. Verificada a confissão da autoria, incide a circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, razão pela qual reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena do réu, já se considerou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade criminosa do

réu, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 38/44, indicam dedicar-se o réu à atividades criminosas, já que ausente comprovação de atividade laborativa. Neste sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A elevada quantidade de drogas apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. 3. A despeito de, no julgamento do REsp n. 1.773.834/ES, a Sexta Turma ter ressaltado que a diretriz fixada comporta prova em sentido contrário, no caso, a Defesa não se desincumbiu desse ônus, pois não há qualquer indicação nos autos que afaste a responsabilidade do Acusado acerca da apreensão de 41,820kg de cocaína e 10,240kg de pasta base do mesmo entorpecente. 4. O redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base não apenas na quantidade de droga apreendida e na forma de acondicionamento, pois as instâncias ordinárias também mencionaram outras circunstâncias do caso concreto aptas a justificar a não concessão da citada benesse e a confirmar que a conduta praticada pelo Réu não é algo casual e isolado, quais sejam; "transporte de droga típico de uma organização com vínculo internacional poderosa, a qual contou com uma teia de colaboradores, sendo importante destacar que o plano arquitetado foi muito bem elaborado e esse tipo de negociação certamente envolve diversas pessoas, e não apenas o transportador da cocaína, nem tampouco o funileiro que a escondeu no veículo, mas também capitalizados compradores e fornecedores." (STJ, AgRg no AREsp 1799093/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021). O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno DOUGLAS MARCATO BARRETO, R.G. n.º 46.145.640, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflictivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO da balança e do rolo de plástico, porque utilizados como instrumentos do crime, bem como do dinheiro e do celular (fls. 24/25), pois obtidos em razão do comércio ilícito.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à

Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.
Custas na forma da lei.
P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA